

0000759-24.2009.8.26.0268

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: LUCAS DADALTO SAHÃO

Comarca: Itapecerica da Serra

Foro: Foro de Itapecerica da Serra

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 23/06/2022

... de Justiça paulista:

Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Recurso da defesa. Pleito objetivando a absolvição. 1. Absolvição de rigor. Fragilidade dos reconhecimentos. Acusado reconhecido, exclusivamente, por meio de fotografias. Ausência de descrição dos traços fisionômicos da pessoa a ser reconhecida. Descumprimento das formalidades previstas pelo art. 226 do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapecerica da Serra

Foro de Itapecerica da Serra

1ª Vara

Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155, Itapecerica da Serra-SP - cep 06850-850

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000759-24.2009.8.26.0268 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000759-24.2009.8.26.0268

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência - 16/2009 - Delegacia de Polícia de Juquitiba, IP 16/2009 - Delegacia de Polícia de Juquitiba, 1093/2008 - Delegacia de Polícia de Juquitiba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Marcio Barbosa da Silva Filho e outro

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS DADALTO SAHÃO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra PAULO RICARDO VIDAL BRAGA DOS SANTOS e MÁRCIO BARBOSA DA SILVA FILHO (fls. 2/4), qualificados nos autos, dando-os como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, incisos I e II, por quatro vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, porque, supostamente, no dia 11 de novembro de 2008, por volta das 15h, na Rua Inácio Vieira Pinto, nº 352, Palmeiras, na cidade de Juquitiba, ajustados e mediante unidade de desígnios com dois outros indivíduos não identificados, por meio de grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para si, os objetos descritos no boletim de ocorrência de fls. 12/13 e no auto de exibição e apreensão de fl. 14, pertencentes às vítimas Carlos Eduardo Emiliano, Claudio Luiz Pousada Dias, Marcos Antonio dos Santos e Paulo Sergio dos Santos.

A denúncia foi recebida em 25.05.2012 (fl. 207).

Devidamente citados, os denunciados apresentaram respostas à acusação, refutando o teor da denúncia (fls. 233 e 234).

Em não se entrevendo hipótese de absolvição sumária, designaram-se audiências de instrução e julgamento.

Nas datas aprazadas, foi colhida a prova oral, e encerrou-se a instrução processual.

Em memoriais, o Ministério Público e a defesa pugnaram pela absolvição dos acusados, por falta de provas da autoria delitiva (fls. 780/783 e 795/796)

É o relatório. Fundamento e decido.

Inexistindo nulidades processuais e/ou preliminares a serem enfrentadas, passo diretamente à análise do mérito da demanda.

A pretensão ministerial improcede.

O sistema penal assenta-se na presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF), de tal sorte que "a sentença condenatória somente pode vir fundada em provas que conduzem a uma certeza. Até mesmo a alta probabilidade servirá como fundamento absolutório, pois teríamos tão-só um juízo de incerteza que nada mais representa que não a dúvida quanto à realidade" (Adalberto José Queiroz Telles de Camargo Aranha, Da prova no Processo Penal, 1994, p. 64). Nos dizeres de HELENO CLÁUDIO FRAGOSO, referida certeza consiste na "conscientia dubitandi secura, de que fala Vico, e não admite graus. Tem de fundar-se em dados objetivos indiscutíveis, de caráter geral, que evidenciem o delito e a autoria (Sauer, Grundlagen des Prozessrechts, 1929, 75), sob pena de conduzir tão-somente à íntima convicção, insuficiente. Afirma Sagatini (Teoria delle prove nel Diritto Giudiziario Penal, 1911, II, 33) que a 'íntima convicção', como sentimento da certeza, sem o concurso de dados objetivos de justificação, não é verdadeira e própria certeza, porque, faltando aqueles dados objetivos de justificação, faltam em nosso espírito as forças que o induzem a ser certo. No lugar da certeza, temos a simples crença" (Jurisprudência Criminal, Forense, 1982, nº 446).

No âmbito processual penal, a presunção de inocência tem ressonância no princípio do in dubio pro reo, o qual impõe ao órgão acusador o ônus de provar os fatos por ele articulados na denúncia e a efetiva responsabilidade criminal do réu (art. 156 do CPP).

No caso concreto, a despeito de os indícios amealhados na fase pré-processual lastrearem a materialidade do crime imputado, apontando os acusados como os possíveis autores, não foram coligidas, em juízo, provas suficientes para a condenação.

Os únicos elementos coligidos aos autos a certificarem a autoria irrogada aos réus consistem nos reconhecimentos fotográficos realizados na fase inquisitorial pela vítima Claudio Luiz Pousada Dias (fls. 21/22) e por sua esposa, Vanessa Martins Xavier (fls. 24/25). Sucede que o primeiro não foi ouvido em juízo, por não ter sido encontrado após anos de busca, ao passo que Vanessa não ratificou, em juízo, com as cautelas estatuídas pelo art. 226 do CPP, o reconhecimento feito em solo policial.

Nesse cenário, os elementos de autoria delitiva são tão somente os informativos, colhidos nos autos do inquérito policial, não podendo lastrear, por si sós, a responsabilização criminal, nos moldes do art. 155 do CPP. Como anotam EUGÊNIO PACELLI e DOUGLAS FISCHER:

'Elementos informativos e elementos probatórios: Rigorosamente falando, o material produzido na fase de investigação não pode ser considerado prova. Ao menos, em princípio.

A fase de investigação, como se sabe, é destinada à formação do convencimento do órgão da acusação e não do magistrado. Na aludida fase, não há preocupação com o contraditório, até mesmo porque sequer se exerce a defesa do acusado. Não há ali, à evidência, ampla defesa. A partir de uma notitia criminis, avança-se para uma apuração sumária de seus elementos comprobatórios, sempre voltada para o convencimento do órgão responsável pelo juízo acusatório. Esse, o juízo acusatório, pode ser positivo, em que há o oferecimento da denúncia ou queixa, ou negativo, hipótese em que se requer o arquivamento da investigação, quaisquer que sejam os

seus fundamentos.

Apenas o material produzido em Juízo é que, a rigor, constituiria prova, abrindo-se necessariamente ao contraditório e à ampla defesa, com efetiva participação da defesa. Em princípio, portanto, apenas a prova se prestaria ao convencimento judicial, não cumprindo essa missão os chamados elementos informativos da fase investigatória.

A nova redação do art. 155, trazida pela Lei nº 11.690/08, inova. E, para pior, a depender da extensão de sua aplicação.

Diz o texto: “não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”. O que significaria isso?

Em primeiro lugar, é de se atentar para o fato de que a expressão “exclusivamente” não constava do anteprojeto original que veio a se transformar na Lei nº 11.690/08.

A ideia inicial era afastar qualquer possibilidade de valoração de material probante produzido unicamente na fase de investigação, ressalvadas as provas cautelares que não pudessem ser repetidas no curso da instrução (interceptações telefônicas, perícias em que já perecido o objeto da prova etc.). Com o acréscimo (do “exclusivamente”), levanta-se, mais uma vez, a questão acerca da possibilidade de formação de convencimento judicial com base em elementos informativos produzidos na investigação.

É de se ver, então, que a inexistência de contraditório e de ampla defesa na fase de investigação preliminar, em princípio, impede a valoração judicial de tais elementos (informativos). Como regra, é claro, já que existem provas, ressalvadas inclusive na citada Lei nº 11.690/08, cuja natureza intrínseca não permite a sua reprodução em juízo. Não se pode, por exemplo, reproduzir a conversa captada em uma interceptação telefônica. Do mesmo modo, não se realiza prova pericial quando o objeto a ser periciado já não se encontra mais à disposição. E, nada obstante, tais meios de prova são aceitos aqui e, provavelmente, na maioria esmagadora dos ordenamentos jurídicos.

É que, em tais situações, o contraditório é diferido, ou seja, é adiado – da fase de investigação para a fase de instrução – permitindo-se que a defesa levante objeções técnicas, do ponto de vista jurídico ou tecnológico, àquele material realizado sem o controle judicial. Por certo que a qualidade das objeções é reduzida, na medida em que se cuida de questionamentos pos factum, sem o alcance das percepções imediatas, em tempo real.

Mas, diante da relevância e da gravidade dos danos causados pela infração penal – eis aqui outra das inúmeras justificativas para um Direito Penal de intervenção mínima –, o Direito se curva à necessidade de flexibilização na interpretação até mesmo de garantias constitucionais.

A expressão “exclusivamente”, portanto, não deve ser entendida como uma porta aberta para a livre valoração do material produzido na investigação, se presentes outras provas colhidas na instrução criminal. Não. Fosse assim, o convencimento judicial poderia ser construído com base essencialmente – e não exclusivamente! – em elementos informativos, bastando apenas a referência à existência de outras provas produzidas em Juízo.

Parece-nos que o tal “exclusivamente” apenas autorizaria um juízo de ponderação, de forma e principalmente de conteúdo, acerca das provas repetidas em Juízo, isto é, sobre a prova colhida na investigação e repetida em juízo'. (Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência – 12. ed. – São Paulo: Atlas, 2020. pp. 410/411). (Negritei).

Na mesma ordem de ideias, preleciona GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

Adotado o sistema da persuasão racional, o juiz pode formar livremente o seu convencimento, desde que fundamente a decisão (art. 155, CPP). Sob o prisma constitucional, seguindo-se o devido processo legal, as provas válidas para a condenação devem ser extraídas do processo judicial, em que há a ampla defesa e o contraditório. Algumas provas podem advir do inquérito policial, quando são periciais e feitas, à época do crime, com urgência (ex.: laudo de local). Em nossa visão, provas que podem ser refeitas em juízo (como a testemunhal), quando realizadas na fase extrajudicial, são inúteis para fundamentar a condenação do réu. (Processo penal e execução penal, 5. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019; São

Paulo: MÉTODO, 2019, p. 82). (Negritei).

O Superior Tribunal de Justiça não destoa da orientação de que a condenação apenas pode ser arrimada em elementos informativos coligidos no inquérito policial quando estes forem reproduzidos em juízo ou corroborados por provas produzidas no curso da ação penal, sob a lente do contraditório:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ARTS. 1º, II E IV, DA LEI N. 8.137/1990, C/C O ART. 71 DO CÓDIGO PENAL, E 11 DA LEI N. 8.137/1990. INQUÉRITO POLICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DESNECESSIDADE. TRANCAMENTO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O inquérito policial é procedimento administrativo instaurado com a finalidade de se colherem elementos de informação acerca de autoria e materialidade de determinado crime, tão somente para o Ministério Público poder dar ou não início à ação penal.

2. Por força de norma prevista no art. 155 do CPP, é vedada a eventual prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase inquisitiva, na qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa). O juiz pode se valer desses elementos informativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual; por isso não se verifica nenhum constrangimento ilegal a que esteja submetido o ora recorrente, ausente, ademais, qualquer prejuízo.

(...).

5. Recurso em habeas corpus não provido." (RHC 47.938/CE, 6ª Turma, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 21.11.2017).

Assento, em remate, que, em recentes julgamentos, a Corte Superior de Justiça vem decidindo que o reconhecimento de pessoa, presencial ou por fotografia, realizado na fase policial, apenas é apto a identificar o réu e a certificar a autoria delitiva se e quando observadas as formalidades procedimentais estatuídas no art. 226 do CPP, e uma vez roborado por outras provas colhidas na etapa judicial da persecução penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (nesse sentido: HC 598.886/SC, 6ª Turma, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 27.10.2020; e HC 652.284/SC, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27.04.2021).

Logo, em atenção do princípio do in dubio pro reo, a absolvição dos acusados, por falta de provas da autoria, é medida de rigor.

Em abono ao motivado, colaciono aresto do Tribunal de Justiça paulista:

Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Recurso da defesa. Pleito objetivando a absolvição. 1. Absolvição de rigor. Fragilidade dos reconhecimentos. Acusado reconhecido, exclusivamente, por meio de fotografias. Ausência de descrição dos traços fisionômicos da pessoa a ser reconhecida. Descumprimento das formalidades previstas pelo art. 226 do Código de Processo Penal. Acusado que não foi preso em flagrante, tampouco foi encontrado em poder dos objetos subtraídos. 2. Insuficiência para decreto condenatório. Ausência de elementos que pudessem vincular o acusado com a prática do roubo. 3. Recurso provido. (Apelação Criminal nº 1500577-43.2019.8.26.0484, 16ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Marcos Alexandre Coelho Zilli, j. 11.11.2021).

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido na denúncia e, por via de consequência, ABSOLVO os acusados PAULO RICARDO VIDAL BRAGA DOS SANTOS e MÁRCIO BARBOSA DA SILVA FILHO, qualificados nos autos, da imputação que lhes foi feita, por incursos no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em razão do presente desfecho decisório, ORDENO a cessação de eventuais medidas cautelares fixadas nestes autos (art. 386, parágrafo único, II, do CPP).

Expeça-se certidão de honorários em favor do patrono nomeado, no valor máximo previsto na tabela vigente.

Transitada em julgado, procedam-se às anotações e às comunicações necessárias. Porque órgão do Estado, o Ministério Público não paga custas, notadamente em procedimento processual penal.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Itapecerica da Serra, 23 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA